

0002635-43.2017.8.26.0491

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Dano

Magistrado: DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... droga, apto a ensejar o incremento do tráfico de entorpecentes, a par de outros delitos associados ao uso indevido da droga. Ademais, deve ser ponderado que o E. Supremo Tribunal Federal, a quem compete o controle de constitucionalidade das normas, em momento algum reconheceu a indigitada inconstitucionalidade, razão pela qual o dispositivo de lei há que ser observado e cumprido. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

2ª Vara

Rua Marcilio Dias, 615, Rancharia-SP - cep 19600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002635-43.2017.8.26.0491 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002635-43.2017.8.26.0491

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 1779/2017 - Delegacia de Polícia de Rancharia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Garavelo Nunes Vieira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Dayane Aparecida Rodrigues Mendes

Vistos.

Rafael Garavelo Nunes Vieira, devidamente qualificado nos autos (fls. 10 e 24), foi denunciado e está sendo processado perante este Juízo como incurso nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso III, e artigo 330, ambos do Código Penal, e do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que o dia 25 de setembro 2017, por volta das 12:15 horas, na esquina da Rua Governador Lucas Garcez com a Rua Cândido de Freitas, nesta cidade e Comarca, RAFAEL GARAVELO NUNES VIEIRA, qualificado às fls. 10 e 24, desobedeceu a ordem legal emanada por policiais civis, consistente em sinal de parada. É dos autos também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, RAFAEL GARAVELO NUNES VIEIRA, qualificado às fls. 10 e 24, deteriorou viatura pertencente ao patrimônio público estadual, mais especificamente à Polícia Civil do Estado de São Paulo, conforme laudo pericial fls. 47/50. Consta do inquérito que, no mesmo dia, durante a tarde, na Rua José Baccarin, nº 240, nesta cidade e comarca, RAFAEL GARAVELO NUNES VIEIRA, qualificado às fls. 10 e 24, guardava e matinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de "Maconha", com peso líquido aproximado de 5,36g (cinco

gramas e trinta e seis centigramas) (cf. laudo a fls. 37/39). Segundo se apurou, na ocasião dos fatos, RAFAEL GARAVELO NUNES VIEIRA empinava sua motocicleta, momento este que fora avistado por policiais que efetuavam patrulhamento e o seguiram. Na esquina da Rua Governado Lucas Garcez com a Rua Cândido Freitas, o denunciado se deparou com os policiais civis mencionados, os quais estavam em uma viatura descaracterizada e lhe deram sinal de parada, porém, mesmo após reconhecer que se tratavam de policiais, o denunciado desobedeceu a ordem e se evadiu do local, conduzindo sua motocicleta em direção à viatura. Então, o denunciado manobrou seu veículo em direção ao automóvel e colidiu contra porta da viatura, deteriorando-a, conforme laudo pericial fls. 47/50. Mais tarde, no mesmo dia, Rafael foi detido pelos Policiais na Rua Péricles Rolim e fora conduzido até sua residência, onde guardou sua motocicleta. Durante as buscas realizadas no local, os policiais localizaram uma porção contendo 5,36 gramas de maconha, a qual, segundo o denunciado, destinava-se ao uso pessoal (fls. 01/04).

Em que pese o flagrante delito (fl. 06), o acusado foi solto ante o pagamento de fiança (fls. 27 e 32).

A denúncia foi recebida em 23 de outubro de 2018 (fls. 131/132).

Regularmente citado (fls. 176), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 170/171) alegando a defesa reserva-se ao direito de apreciar detalhadamente o mérito da ação quando das alegações finais.

Refutada a hipótese de absolvição sumária, conforme decisão de fls. 238/240.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais em audiência vindo os autos conclusos para sentença.

O Ministério Público, em suma, requereu a procedência da denuncia; sustentou que está ausente prescrição considerando que entre os atos interruptivos não foi superado o prazo de dois anos; quanto à dosimetria, o réu é primário, devendo ser aplicada a pena mínima; quanto ao art. 28 da Lei 11.343/06 pediu a pena de advertência; quanto aos demais delitos, o regime aberto, com substituição por pena de multa, conforme gravação.

A defesa, em suma, requereu a absolvição; sustentou que o réu não frequenta a delegacia, trabalha produzindo camisetas e serviços gerais; a abordagem da polícia civil foi desastrosa; o réu acreditou que poderiam ser bandidos, pois os policiais estavam com armas em mãos, porém, sem caracterização da polícia; o réu não pretendeu desobedecer a ordem de parada; não havia flagrante, pois o réu não foi perseguido nem foi encontrado logo após com objeto do crime; o réu não conseguiu cumprir o acordo com o Ministério Público porque não tinha condições de pagar; pede a nulidade das provas obtidas na residência e absolvição do réu, no mérito, por ausência de provas, ausência de dolo, conforme gravação.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da conduta delitiva descrita no artigo 163, parágrafo único, inciso III, e artigo 330, ambos do Código Penal, e do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Não havendo nulidades ou questões de cuja prévia e imediata solução dependa o avanço a essa seara, conheço diretamente o mérito. A pretensão punitiva estatal é PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos da fundamentação que se passa a expor.

O artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal assim descreve o delito de dano qualificado: "Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Parágrafo único - Se o crime é cometido: III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;".

Em que pese o auto de prisão em flagrante delito (fl. 06), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de entrega (fl. 17) e auto de avaliação (fl. 80), não há provas suficientes para a condenação do réu em relação aos art. 163, parágrafo único, III e art. 330, ambos do Código Penal, salvo em relação ao crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 à luz do laudo pericial (fls. 41/43 e 51/54) e da confissão do réu em Juízo.

O artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06 assim descreve o delito: "Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal,

drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo."

A autoria foi demonstrada pelos depoimentos colhidos em audiência.

A testemunha de acusação José Carlos Martins Carreira, policial civil, disse que se recorda de partes da ocorrência; que estavam nas ruas de Rancharia e avistaram um moto "empinando"; fizeram a abordagem e o condutor da moto jogou a moto na viatura; o condutor saiu no lado oposto; a viatura era descaracterizada, era uma Parati cinza; na tentativa de evadir, o condutor bateu na porta do veículo e saiu; que novamente avistado, porém, sem a moto, mais tarde no mesmo dia, abordaram o réu e ele seguiu mostrando a moto na residência do réu; não verificaram adulteração de veículo; na ocasião encontraram uma porção de droga e certa quantia em dinheiro na residência; o réu era conhecido nos meios policiais, conforme gravação.

A testemunha de acusação Hamilton Tadeu Dorne e Silva, policial civil, disse que estavam em patrulhamento próximo à escola municipal; que tinham conhecimento de uma pessoa com moto com placa adulterada dias antes; a moto fez manobras; estavam numa viatura descaracterizada; que interceptaram a moto, ocasião em que o réu acelerou a moto e saiu no sentido contrário; pouco tempo depois souberam que o réu estava próximo e seguiram até lá; perguntaram da moto e o réu informou onde a moto estava; que era a residência do réu; a moto não estava com a placa adulterada; encontrou uma porção de drogas em cima do guarda roupas e o réu disse que era para consumo pessoal; assim que abordaram disseram que era a polícia; era bem conhecido na cidade como sendo policial; apontou a arma para que o réu parasse a moto; o réu estava usando capacete; que na época trabalhavam apenas três policiais civis na cidade de Rancharia e eles eram conhecidos, conforme gravação.

A informante Silvana Maria Garavelo disse que é mãe do réu; que se recorda dos fatos; que o réu disse que não sabia que quem abordou era a polícia; que depois os policiais o levaram para sua casa; a polícia entrou na casa sem o seu conhecimento pois não estava presente; enquanto menor de idade o réu já teve problemas e ficou cerca de 30 dias na fundação Casa; maior de idade ele não teve problemas com a polícia; a sua casa ficou revirada pelos policiais; que ficou apavorada; a moto do réu foi comprada de uma vizinha e ficava na casa; a moto era regular, conforme gravação.

Interrogado, o réu Rafael Garavelo Nunes Vieira afirmou que 23 anos, sem filhos, "segundo colegial completo", trabalha na empresa chamada Casa da Sogra em Rancharia, já foi apreendido quando menor por motivo de drogas. Sobre os fatos disse que empinou a moto; o policial Hamilton estava com arma na mão e mandou parar; assustou e foi embora pois não sabia que eram policiais; que foi para casa da sua vó e no bar; mais tarde lhe pararam novamente dando voz de prisão perguntando da moto; disse que a moto estava em casa, eles entraram na sua casa e o levaram para delegacia; pagou fiança para sair da prisão; que mesmo eles gritando polícia não parou a moto porque não estavam caracterizados, o carro e a roupa eram "normais", sem roupa de polícia; que abriram a porta para lhe derrubar; não jogou a moto contra o carro; que tinha um "baseado" na casa para consumo pessoal, conforme gravação.

Embora o depoimento dos policiais tenha fé pública, o fato da abordagem ter sido realizada por viatura e policiais descaracterizados deixa dúvidas se o réu não atendeu ao sinal de parada por medo ou por desobediência. Isso porque, no mesmo dia, na segunda abordagem o réu, agora ciente, sem dúvidas, de que se tratavam de policiais prontamente informou onde estava a moto e levou os policiais até sua residência.

A dúvida substancial também remonta quanto ao dano na viatura, se ocasionado por dolo do réu ou na tentativa de fazer o réu parar a moto.

O "empinar" moto, em tese, não configura infração penal, de modo que não havia situação de flagrância. Na segunda abordagem não se constatou adulteração ou irregularidade na moto que era conduzida pelo réu, afastando a hipótese de crime permanente.

Quanto ao crime de uso de entorpecentes, por sua vez, a mesma sorte não assiste o

réu, considerando que trata-se de crime permanente, tendo o réu inclusive confirmado que a porção realmente lhe pertencia, estava em sua residência e se destinava para consumo pessoal.

O crime de posse de entorpecente para consumo pessoal trata-se de delito de perigo abstrato que se concretiza pela simples realização da conduta típica descrita pela norma penal, advindo, daí, a presunção do legislador acerca do risco à que é exposto o bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja, a saúde pública. A criminalização da conduta de posse de droga destinada ao consumo pessoal não ofende princípios constitucionais, e tampouco é desproporcional ou atípica. Nesse sentido: "[...] A punição, na hipótese, é de rigor para salvaguardar a sociedade do mal potencial causado pelo porte de droga, apto a ensejar o incremento do tráfico de entorpecentes, a par de outros delitos associados ao uso indevido da droga. Ademais, deve ser ponderado que o E. Supremo Tribunal Federal, a quem compete o controle de constitucionalidade das normas, em momento algum reconheceu a indigitada inconstitucionalidade, razão pela qual o dispositivo de lei há que ser observado e cumprido. [...]" (STF - RE: 635660/SP, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento: 22/03/2011, DJe: 06/04/2011).

Ainda, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui julgado nesse sentido: "Porte de entorpecentes para uso pessoal Apelo da Defesa buscando a absolvição pela atipicidade da conduta ante a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 Impossibilidade Criminalização que não ofende os princípios constitucionais Coibição que busca resguardar a saúde pública Condenação mantida. Pena bem fixada e condizente com as circunstâncias do crime e a personalidade do réu. Recurso improvido." (TJSP; Apelação Criminal 1501300-36.2018.8.26.0019; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Americana - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)

Assim, não há que se falar em conduta atípica.

Quanto ao princípio da insignificância, a sua inaplicabilidade no presente caso decorre do mesmo raciocínio, tendo em vista que em se tratando de crime de perigo presumido ou abstrato, a pequena quantidade de substância entorpecente é própria do tipo, assim a conduta do réu viola a norma que visa evitar exatamente o uso.

A conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06 não faz qualquer ressalva à quantidade de droga necessária a configuração do delito. Nesse sentido: "(...) USO DE ENTORPECENTE PEQUENA QUANTIDADE TIPICIDADE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPROPRIEDADE RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO (...) II. A pequena quantidade de substância entorpecente não desnatura o crime de uso. Precedentes. III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido" (STJ RESP n.º 604076 MG 5ª Turma Rel. Min. Gilson Dipp DJU 20.09.2004 p. 00326).

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento que tem prevalecido é no sentido de impossibilidade de insignificância ao crime do artigo 28 da lei de drogas. O fundamento empregado é justamente o fato de ser o crime de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria. O réu era, na data dos fatos, imputável e tinha plena consciência da ilicitude, inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude legal (art. 23, CP) ou supralegal, nem de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou os delitos descritos na denúncia, razão pela qual deverá responder criminalmente.

Passo a dosar a pena.

Quanto ao delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06

Considerando as sanções previstas no art. 28 da Lei 11.343/06, aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses em local a ser definido oportunamente pelo Juízo da Execução. Essa reprimenda possui cunho pedagógico para que o acusado reflita seu envolvimento com as drogas e evite novamente o uso de maconha.

**DISPOSITIVO**

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu Rafael Garavelo Nunes Vieira, RG: 58.299.518, qualificado às fls. 10 e 24, da prática dos crimes previstos no artigo 163, parágrafo único, inciso III, e

artigo 330, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e CONDENA-LO pelo crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses, em local a ser indicado pelo Juízo da Execução Penal.

O réu permaneceu solto durante o processo e, inexistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, CPP), concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (Súmulas 9 e 347, STJ), salvo se por outro motivo estiver preso (art. 387, §1º, CPP).

Condene o réu ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro, se assistidos por advogado do Convênio entre a OAB e Defensoria Pública/SP. Anote-se.

Após o trânsito em julgado expeça-se guia de execução penal, oficie-se ao T. R. E para fins do cumprimento do art. 15, III, da CF/88 e oficie-se ao Instituto de Identificação Civil e demais comunicações e anotações de praxe.

Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado para atuar em defesa do réu (fl. 172), intimando-o para retirada por meio do acesso eletrônico aos autos digitais do processo no prazo de cinco dias.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, §6º das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Rancharia, 12 de Agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA